

1500668-63.2021.8.26.0129

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... para que seus familiares participem do tráfico drogas no interior dos presídios. A adesão ao pedido, porém, é opção do familiar. No caso em tela, os manuscritos evidenciam o envolvimento do réus no tráfico de drogas, uma vez que constam menções explícitas ao comércio de substâncias ilícitas.

Consigo que opera-se o crime impossível pela ineficácia absoluta domeio empregado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500668-63.2021.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500668-63.2021.8.26.0129

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2269508/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 20619252 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 866/21/200 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2269508 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2269508 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 866/21/200 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAIANE TABATA PINHEIRO COSTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de DAIANE TABATA PINHEIRO COSTA, qualificada nos autos, e RAUL GUILHERME COSTA, qualificado nos autos, sendo-lhes imputado o crime previsto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 03 de outubro de 2021, por volta de 11h15min, na Penitenciária "Joaquim de Sylos Cintra", localizada neste município e Comarca de Casa Branca, DAIANE e RAUL, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, ocultavam e traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, cinco unidades de ADB-BUTINACA, substância entorpecente sintética conhecida popularmente por "K4",

que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré DAIANE TABATA PINHEIRO COSTA apresentou defesa prévia às fls. 222/223.

O réu RAUL GUILHERME COSTA ofereceu defesa prévia às fls. 254/256.

A denúncia foi recebida em 26 de maio de 2022.

Realizada audiência de instrução, foram as ouvidas as testemunhas arroladas e os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação na forma da denúncia e as Defesas advogaram teses absolutórias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do fato restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 6/7), pelo auto de apreensão (fl. 8), pelo laudo pericial de fls. 61/67, pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 68/73), pelo procedimento administrativo disciplinar (fls. 81/144), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 164/166) e pela prova oral produzida.

A autora é certa e recai sobre a pessoa dos acusados.

ANA CLÁUDIA ALVES, agente penitenciária, em juízo, informou que lembra-se que, na data dos fatos, quando Daiane saiu da unidade, ela apresentava nervosismo em excesso e, por isso, foi chamada a uma sala reservada. Inicialmente ela negou qualquer irregularidade. Após, em revista, no top dela, havia um volume com um maço de cigarro. No interior deste maço, existiam três bilhetes, onde estavam embrulhados 5 pontos de K4, droga sintética. Existiam três manuscritos com recados, orientações sobre esconderijo e ordens de envio de drogas. Ela disse que recebeu essa embalagem de seu companheiro Raul. Ela disse que não sabia da droga. Não sabe do valor de venda do selo de K4. Sabe que K4 foi proibida por facção criminosa. Fez a revista em Daiane com sua companheira Juliana. As drogas foram encontradas durante a revista. Presos e visitantes ficam sozinhos no raio durante a visita. A revista é feita em todas as pessoas na entrada. Na saída, os visitantes só passam por revista caso se verifique alguma atitude suspeita.

ELIEL GOMES DA SILVA, agente penitenciário, disse, em juízo, que trabalha na portaria da unidade prisional de Casa Branca. Apresentou relato no mesmo sentido de sua colega profissional. Acrescentou que no interior do maço de cigarro MARLBORO, localizou manuscritos com informações do tráfico de drogas e números de telefone, bem como pontos da drogas sintética K4. Inicialmente, ela negou qualquer irregularidade. Depois da localização dos manuscritos e das drogas, ela indicou que havia recebido este maço do companheiro no interior da unidade. Não sabe sobre a conduta de Raul no cárcere por trabalhar apenas na portaria. K4 é uma droga nova.

Não sabe a respeito do valor de venda da substância. Não estava dentro da sala reservada, tendo em vista que a revista foi feita por agentes do sexo feminino.

FABIO GIZZI DE MARQUE, diretor de segurança e disciplina da unidade prisional, contou, em juízo, que não tinha conhecimento da possível ocorrência em relação à esposa do sentenciado. A apreensão ocorreu pela percepção da agente penitenciária que trabalhava no dia dos fatos. Tinha notícias, embora não comprovadas, ligando RAUL ao tráfico na unidade prisional e informação de ele integrar facção criminosa.

DAIANE TABATA PINHEIRO COSTA, em seu interrogatório, afirmou que tem 33 anos.

Estudou até a sétima série. Saiu do trabalho para cuidar de sua mãe que perdeu a visão. Trabalhava em uma loja de eletrodomésticos como vendedora. Tem dois filhos com Raul, com 13 e 10 anos de idade. Este é seu primeiro processo criminal. Os fatos são verdadeiros. Não sabia da existência de drogas embrulhadas nos bilhetes dados por Raul. Raul pegou estes bilhetes do menino "faxina". Não apoia drogas e Raul nunca tinha pedido algo nesse sentido para sua pessoa. Pensava que no interior existiam apenas recados para familiares dos presos. Nunca tinha sequer visto essa droga conhecida por maconha sintética. Foi a primeira vez que aceitou sair com um bilhete. Considera-se inocente. Achou estranho o fato de se tratar de saída de drogas do interior da unidade quando o que ouve dizer é sobre entrada de drogas. Não imagina que Raul pudesse fazer algo para prejudicá-la. Podem ter sido vítimas de alguma trama. Ele pode ter inimigo. Raul usava drogas socialmente na rua. Não sabe a respeito do uso de drogas dele no interior da unidade. Na visitas, os

"faxinas" cuidam de recados (entre funcionários e presos com e sem visitas). Raul não abriu as cartas dadas pelo faxina, apenas colocou no bolso. RAUL GUILHERME COSTA, em seu interrogatório, disse que tem 30 anos. É de Paulínia. Tem dois filhos, com 13 e 10 anos de idade. Ambos saudáveis e bem cuidados. Estudou até oitava série. Trabalhava como ajudante geral, pintor. Está preso por roubo e por furto. Não tem outros processos. Nega o tráfico de drogas. Nunca comercializou drogas na unidade. Não teve encomenda. Apenas pediu um favor para sua esposa entregar uma carta de outro sentenciado. Ela acabou aceitando. Não sabia do conteúdo da carta. Não abriu. Pediu para sua esposa levar a carta mesmo, mas não comercializava drogas na prisão. Era usuário de COCAÍNA e, diante da ausência desta substância no cárcere, passou a fazer uso de K4. Não é integrante de facção criminosa. Tinha 3/4 K4 no bolso e possivelmente saiu do seu bolso junto quando foi entregar a carta à sua esposa. É casado com DAIANE há muitos anos e ela acreditava que sua pessoa tinha parado com o uso de drogas. Ela não tinha ciência que saía com drogas da unidade, mas apenas da carta. Insistiu a ela para que fizesse esse favor. Das provas carreadas aos autos, reputo devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas imputado aos réus. É que ficou nítido que os réus ocultavam e traziam consigo drogas para o consumo de terceiros. As palavras dos agentes penitenciários devem ser acatadas por merecerem crédito. De fato, são servidores públicos, concursados, nos quais o Estado deposita confiança para desempenho do mister. Seria verdadeira contradição o mesmo Estado, agora na função jurisdicional, afastar ou diminuir o valor das palavras dos agentes públicos que apuraram os fatos. Saliento que nada nos autos indica o desejo dos servidores de imputar condutas tão graves aos réus de maneira inverídica.

Nesse sentido:

"Vale ressaltar que os relatos dos agentes penitenciários envolvidos na apreensão das drogas são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu. A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis". (Apelação nº 1501774-69.2018.8.26.0548 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. César Augusto Andrade de Castro julgado em 04/12/2019).

Os réus negaram a prática do tráfico de drogas, porém não deram qualquer explicação plausível e convincente para os fatos retratados nos autos. A tese de autodefesa dos acusados de que não tinham ciência da existência das drogas não deve prosperar, vez que está divorciada do conjunto probatório dos autos.

Embora a ré assevere que não sabia da existência das drogas, fato é que tomou atitude incompatível com o alegado desconhecimento, tendo ficado nervosa e escondido as drogas em suas vestes. Já a versão do réu de que entregou à companheira drogas que estavam no seu bolso por engano carece de verossimilhança, notadamente diante do acondicionamento das substâncias no interior de maço de cigarro.

Como se vê, as declarações dos acusados não demonstraram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos e as versões dadas por eles são dissonantes do que fora apurado durante a instrução criminal. Os argumentos, portanto, mostram-se inverossímeis, por não encontrarem respaldo fático.

Percebe-se, enfim, nos discursos, o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual as versões por eles apresentadas não podem ser aceitas.

Consigno, por oportuno, que é cediço que pode haver pressão ou até mesmo ameaças pelos sentenciados para que seus familiares participem do tráfico de drogas no interior dos presídios. A adesão ao pedido, porém, é opção do familiar. No caso em tela, os manuscritos evidenciam o envolvimento do réus no tráfico de drogas, uma vez que constam menções explícitas ao comércio de substâncias ilícitas.

Consigo que opera-se o crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado ou pela absoluta impropriedade do objeto, o que não se verifica no caso em tela. A vistoria nas visitantes e em seus pertences, ainda que minuciosa, dificulta a entrada de entorpecentes na penitenciária, mas não a torna impossível. Do contrário, não haveria tantos procedimentos de igual natureza no sistema prisional. Além disso, o crime se consumou nas modalidades trazer consigo e ocultar, do que se extrai que antes mesmo da apreensão das drogas pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado, sendo desnecessário que a droga de fato ingressasse no presídio. Esse tem sido o entendimento das Câmaras de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos:

"Inicialmente, buscam os Apelantes suas absolvições, aduzindo se tratar de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio, isso porque a existência de scanner no estabelecimento prisional impediria, de qualquer forma, a consumação do crime. Para caracterização de crime impossível, é necessário não existirem meios de o agente conseguir chegar à consumação do crime, o que não ocorreu no caso dos autos. O fato do estabelecimento prisional possuir um scanner na revista, o que impediria o ingresso de materiais não permitidos, não é garantia de que JULIANE não conseguiria atingir seu intento". (Apelação nº 1500429-58.2019 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Luis Antônio Cardoso julgado em 03/12/2019).

"Ademais, a conduta é típica, ainda que o apelante não tivesse conseguido efetivamente tomar posse da droga dentro do presídio. Desta forma, sendo o tráfico de drogas um tipo penal de conteúdo misto alternativo, qualquer das condutas descritas em seu preceito primário tipifica o delito". (Apelação nº 1500321-58.2018.8.26.0283, 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Tozola Neto julgado em 12/12/2019).

"Ademais, não se exige prova de que alguma pessoa tenha efetivamente adquirido entorpecente do acusado, eis que, para a caracterização do tráfico, não é necessário que o indivíduo esteja praticando algum ato de mercancia, bastando que exista apenas uma das condutas previstas pelo art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla. Ou seja, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, adquirir e remeter entorpecentes para consumo de terceiros, o que no caso restou comprovado". (Apelação nº 1501687-79.2018.8.26.0624, 11ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Guilherme G. Strenger julgado em 04/09/2019)

Portanto, demonstradas a autoria e a materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isentem os agentes de pena, mostra-se rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do CP.

Em relação à ré DAIANE, em atenção ao disposto nos artigos 42 da Lei de drogas e 59 do Código Penal, observo que a acusada é primária (fl. 202). Não há nos autos elementos desfavoráveis no tocante à conduta social e personalidade da acusada, nem aos motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Ressalto que, em respeito à vedação ao bis in idem, a natureza da droga não será considerada neste primeira fase, pois servirá como fundamento para a dosagem do redutor do redutor do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparo. A consideração da quantidade e natureza dos entorpecentes na 1ª etapa, para elevar a pena-base, e na 3ª fase, para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, configura vedado bis in idem. Afastado o incremento aplicado sobre a basilar. Relevante quantidade de drogas variadas que impede a redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da referida lei. Regime inicial semiaberto que melhor se amolda à espécie e às finalidades da sanção penal. Inviável por disposição legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1504022-27.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo

Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021)

Assim, fixo a pena-base privativa de liberdade no mínimo legal, qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, ausentes as agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, por conta do disposto no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (delito cometido nas dependências de estabelecimento prisional), aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, tendo em vista que a natureza das drogas, por si só, não impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 (a propósito: AgRg no AREsp 1955819/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022), impõe-se o reconhecimento do privilégio.

De todo modo, a acusada portava droga de natureza sintética (ADB-BUTINACA) para tentar ingressar no interior de um estabelecimento prisional, de forma que o redutor será fixado no patamar de 1/3 (um terço). Assim, fixo a pena definitiva em 2 anos e 11 meses reclusão e 291 dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada e a natureza da droga apreendida, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/2006.

Como assentado pelo Tribunal Pleno do Colendo STF, "... o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminoso ..." (STF, HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016)

Desse modo, reconhecido o privilégio, diante da quantidade da pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta por duas penas restritivas de direitos consistentes em: a) limitação de fim de semana, pelo prazo da condenação, nos moldes a serem indicados pelo douto Juízo das execuções e; b) prestação de serviços à comunidade.

Em relação ao réu RAUL, é de se notar que, pela certidão de distribuição criminal de fls. 203/205, o réu possui duas condenações criminais definitivas: 1) Foro de Cosmópolis, Vara Única, Ação Penal, Procedimento Ordinário: 0000594-

63.2016.8.26.0548 - 0003034-05.2018.8.26.0502, data do fato: 20/05/2016, art. 155, § 4º, I e IV do CP e art. 244-B do ECA, trânsito em julgado em 20/11/2017; e, 2)

Foro de Paulínia, 1ª Vara, Ação Penal, Procedimento Ordinário: 0003029-

55.2011.8.26.0428 - 0003029-55.2011.8.26.0428, data do fato: 20/08/2010, art. 157, § 2º, I e II do CP, trânsito em julgado em 17/09/2018. Daí porque uma será considerada a título de maus antecedentes e outra a título de reincidência.

Na primeira fase, em atenção ao disposto nos artigos 42 da Lei de drogas e 59 do Código Penal, observo que o acusado ostenta maus antecedentes e que, apesar de pequena quantidade em termos de massa, a droga apreendida é sintética (ADB-BUTINACA). Assim, considerando as circunstâncias mencionadas, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, presente a agravante da reincidência e, ausentes as atenuantes, agravo a pena em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, por conta do disposto no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (delito cometido nas dependências de estabelecimento prisional), aumento a pena em 1/6 e, não havendo causas de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em

07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Outrossim, deixo de aplicar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no artigo 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, em consideração aos maus antecedentes, à reincidência e à gravidade em concreto da infração.

Igualmente, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena, em razão do montante da pena aplicada, da reincidência e dos maus antecedentes.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da ação penal para 1) CONDENAR a ré DAIANE TABATA PINHEIRO COSTA, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto 33, "caput" e § 4º, c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, à pena de 2 anos e 11 meses reclusão no regime inicial semiaberto e 291 dias-multa, estes fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos; e, 2) CONDENAR o réu RAUL GUILHERME COSTA, pela prática do crime previsto 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão no regime inicial fechado e 793 dias-multa, estes fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Em respeito ao princípio da contemporaneidade (art. 315, §1º do CPP), não há razão para o decreto de segregação cautelar nestes autos, em que pese a gravidade em concreto do delito.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Tendo em vista que não existem dúvidas sobre a natureza e quantidade das substâncias, tampouco acerca da regularidade dos laudos toxicológicos, determino a destruição por incineração das drogas apreendidas, preservando-se amostras mínimas necessárias para eventual contraprova (art.58, §1º c/c art.32,§ 1º da Lei nº 11.343/06).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, no valor máximo, em prol dos patronos que atuaram no feito em função do convênio da assistência judiciária.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral dos apenados para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); (2) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); (3) intimem-se os condenados para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuarem o pagamento da multa (art. 50, caput do CP); (4) arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.

P. I. C.

Casa Branca, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA